第4题：民诉综合案例分析题（约52-56分）

- **第4题：民诉综合案例分析题（约52-56分）**
  - 题型特点：“大案例”题
    - 考查重点：10-14问
      - 民法： 合同效力、违约责任、物权变动、担保（抵押、质押、保证）、侵权责任等
      - 商法： 公司法（股东权利、股权转让、公司治理）、合伙企业法、破产法等
      - 民事诉讼法： 管辖、当事人确定、证据与证明、一审、二审、再审、执行程序等
  - **一、厚大民法案例**
    - 案例1：公司债券案
      - 1、乙拒绝订立债券认购合同后果如何
        - 意向书未约定债券认购的全部要件属于预约，认购合同对债券认购的认购数额和利息等问题加以明确属于本约。乙公司拒绝订立认购合同属于预约的违约，甲公司有权追究乙公司基于意向书的违约责任
      - 2、甲能否主张8%年利率利息
        - 不能。债券募集说明书属于要约邀请，乙公司关于购买数额、利率、担保的表示属于要约，甲公司同意属于承诺，双方就债券认购事宜形成了合意，甲公司应根据认购合同10%的年利率支付利息
      - 3、债权转让合同性质如何
        - 债权转让合同性质是担保。乙公司将其对丁公司的债权转让给丙构成虚假的意思表示，其隐藏的意思表示是由丙对甲乙债券认购的履约进行担保
      - 4、丙对乙的担保性质如何
        - 属于连带责任保证。甲乙丙约定，甲乙订立《债券认购合同且甲如约向乙公司兑现债券本息，债权转让合同解除，由于未约定担保与主合同债权的履行顺序且没有具体的担保物，故属于连带责任保证。丙为甲的唯一股东，丙为子公司担保无需股东会决议，担保有效。
      - 5、乙能否请求支付3000万
        - 不能。甲公司应根据10%的利率向乙支付利息，未足额履约构成主合同违约，丙作为连带责任保证人对甲未履约部分承担连带责任，基于担保的从属性，担保责任数额不得大于主合同责任数额
    - 案例2：法人设立案
      - 1、a不同意增加租金，b能否拒绝出租办公楼
        - b公司不能拒绝出租办公楼。业务经理王某作为b公司员工有权代理b公司的租赁业务，并与a公司达成租赁协议，b公司应依据租赁协议约定向a公司收取租金。b公司租赁办法属于内部规定、无对外效力，王某对内部规定与协议约定的差额租

金部分构成表见代理，b公司应承担该部分合同后果，b公司不能依据内部规定直接向a公司主张租金

- 2、c可否拒绝承担担保责任
  - 不能。公司对外担保需经股东会决议，c公司法定代表人丁某就担保事宜邮询全体股东意见并获同意，丁某代表c公司签订的对外担保合同有效，c公司不能拒绝承担保证责任
- 3、a可对d的函件主张什么权利
  - 损害赔偿请求权。a公司承租办公楼后，b公司将办公楼卖给d公司，未通知a且给d公司办理了登记，侵害了a的优先购买权。b公司给d公司办理过户登记前a公司未占有办公楼，因此不能主张买卖不破租赁
- 4、a可对建设银行的函件主张什么权利
  - 同等条件下的优先购买权
- 5、a能否抗辩b的解除合同主张
  - 到期未履行，或者违约或者抗辩。题中a公司的租赁办公楼面临买家腾房及抵押权银行变价受偿等主张，租赁难以为继可基于不安抗辩权拒交租金
- 6、建设银行能否拒绝a代为履行
  - 不能。a公司对办公楼具有代为履行的利益，抵押权人不能拒绝
- 7、a代为履行后享有哪些民事权利
  - 对b公司享有债权追偿权，对建设银行办公楼的抵押权

- 案例3：机器设备买卖案
  - 1、买卖合同是否成立
    - 盖章要式合同，未盖章合同不成立，主要义务一方履行、另一方接受的合同成立
  - 2、甲能否就设备b优先于丁受偿
    - 不能。丁诉请法院扣押设备b相当于在设备b上设定了登记了的抵押权，可优先于对甲设定的未登记的抵押权
  - 3、丁可否留置货车c
    - 货车c与800万债权不具有同一性，丁的债权形成于借款、并非商事营业债权，丁不可基于商事留置权留置货车c
  - 4、可否拒绝承担担保责任
    - 可以拒绝。马小云为甲担保的性质属于连带责任保证，未约定保证期的为债权到期后的6个月，甲公司主张已逾期
  - 5、诉讼请求是否成立
    - 履行期届满后的以物抵债协议，债权人应先主张履行抵债协议，债务人不履行的才能主张原债原债或抵债变价受偿之间二选一
  - 6、抵债协议应以哪一套房抵债
    - 房屋d或c为选择之债，未约定选择权的由债务人丙公司选择，丙公司合理期限内无法选出的由债权人选择

- 案例4：挖掘机买卖案
  - 1、挖掘机质量缺陷引发重大事故，乙可主张哪些民事权利
    - 可基于合同目的无法达成主张根本违约解除合同，可基于欺诈主张撤销合同，可基于交货不符主张违约，可基于交货不合格主张付款抗辩权，付款期到了可基于受损主张抵销权
  - 2、甲针对丙提出的诉讼请求法律依据是什么
    - 未设定请求权，构成代为受领，没有债权请求权，不能追究违约责任，也可以主张代位权
  - 3、乙第一个抗辩事由能否成立
    - 债务人与次债务人的仲裁协议、管辖协议，不影响代位权之诉的提起
  - 4、乙第二个抗辩事由能否成立
    - 代位诉提起后，债务人对次债务申请仲裁的，不能豁免怠于履行债权
  - 5、乙第三个抗辩事由能否成立
    - 代位诉提起后，债务人对次债务人免除债务、延长债期的，代位诉不受影响
- 案例5：办公楼装修案
  - 1、四方协议效力如何
    - 债权转让协议，甲和宋在协议上签字意味着债权转让通知了债务人和担保人
  - 2、乙能否请求宋大江承担保证责任
    - 无权，甲由于设备a存在质量瑕疵而可主张对乙的先履行抗辩权，连带保证人可基于甲的抗辩权主张拒绝承担保证责任
  - 3、乙能否主张抵销权
    - 不能，若甲对乙的抵消主张异议
  - 4、三方协议效力如何
    - 债务转让，签三方协议意味着取得了债权人的同意
  - 5、秦光明可否主张抵销权
    - 债务转让，抵销权不延续
  - 6、宋大江是否承担保证责任
    - 不需要承担保证责任，债务转让未经保证人书面同意担保责任消灭
- 案例6：房屋租赁案
  - 1、建设银行能否取得房屋a抵押权
    - 建设银行能取得房屋a的抵押权。不动产异议登记可阻却善意取得，包括抵押权。房屋登记于熊大名下，熊二未办理异议登记，熊大抵押房屋构成无权处分，建设银行能善意取得抵押权
  - 2、如熊大未清偿贷款，建设银行主张房屋a的抵押权，翠花可怎么办
    - 先租后押，翠花可对建设银行主张买卖不破租赁；占有承租人，翠花可在同等条件下对建设银行的变价受偿主张优先受让权

- 3、熊大、熊二、建设合同中谁有权请求翠花支付房屋a租金
  - 熊大有权收取翠花第二年的租金。房屋a作为抵押物未被法院查封、扣押，因此建设银行无权收取租金孳息冲抵抵押物；熊二虽然是房屋的所有权人，但不是租赁合同的相对人，翠花无法依据租赁协议直接将租金交给熊二；熊大出租房屋属于无权处分但租赁合同有效，熊大基于租赁协议收取租金后，熊二有权依据不当得利要求熊大返还
- 4、熊大对翠花的抗辩是否于法有据
  - 熊大撬门拿走翠花物品由于不紧急所以不构成自助；熊大对物品不能合法占有、没有同一性且不属于商事企业，故没有留置权；熊大因故意或过失造成债务人翠花损失，不能主张抵销权
- 5、汽车b上存在几项抵押权，受偿顺位如何
  - 翠花购买了4s店抵押了的汽车b，由于未支付全款因此不能构成正常买受人，工商银行的抵押权依旧有效；翠花将汽车b在收车的10日内为4s店办理了抵押登记，4s店是翠花在汽车b上的价款担保人，可优先于翠花的其他担保权；翠花将汽车b抵押给熊大来担保租金，为第三顺位担保权人
- 6、4s点对青花瓷瓶是否享有留置权
  - 4s店对青花瓷的占有与运输公司欠付租金之间没有同一性，且4s店的债权并非商事营业债权

- 案例7：房屋买卖案
  - 1、胡是否对东湖公司负担债务，马小云是否承担担保责任
    - 对东湖地产负担借款债务，马小云不承担担保责任。债权转让履行了通知义务，债权转让对债务人和担保人发生效力，金钱债权内部禁转约定不得对抗任何第三人，东湖地产成为新债权人后，债务转让取得了东湖地产的同意，由于担保人马小云未书面同意，因此马小云不承担债务转让后的担保责任
  - 2、东湖公司解除通知胡未予理会，是否解除
    - 原材料上涨是正常市场风险，不属于情势变更的法定解除情形，双方无其他约定解除权，东湖地产不能解除合同
  - 3、胡提出的三项抗辩理由是否成立
    - 胡提出的三项抗辩均不能成立。第一，汇款60万未明确支付的是何款，按债务抵充顺序，借款与房款均到期且无担保，借款债务较大支付的是借款；第二，分期付款违约经催告仍不履行，债权人可主张剥夺分期利益要求一次性付全款，无需解除合同；第三，东湖公司已履行交房义务，胡没有抗辩权
  - 4、商品房合同何时解除
    - 起诉解除合同后撤诉、未解除，附条件解除通知、条件达成则解除，第二次起诉解除合同属于确认合同解除效力
  - 5、东湖公司可对胡主张哪些民事权利
    - 合同解除后，东湖公司可主张违约金，胡恶意违约、违约金过高不能调减。东湖公司可主张返还房产、支付房产使用费，胡可主张返还房款、支付资金占用费，

可抵消。东湖公司可主张胡赔偿可得利益损失。

- 其他案例：土地使用权转让
  - 违反未向国家缴清费税不得转让土地使用权规定，不能主张土地使用权转让合同无效
  - 关联交易直接认定为不等价有偿+向知情股东买=可撤销
  - 建筑工程优先权——全楼，优先于抵押权受偿，限于实际支出的工程款
- 其他案例：南湖公司借款
  - 登记了的让与担保变价受偿可优先
  - 客运合同当事人公司的员工，在使用客运服务时性质为第三人代为受领，员工不具有基于合同的违约请求权
  - 可得利益的违约赔偿，以债务人“订立合同时”预见为前提，案中专车用车构成双方客运合同的组成部分，且用车方明确告知了可得利益，因此违约要赔可得利益损失

- **二、厚大民诉案例**
  - 案例一：汽车买卖合同纠纷
    - 1、将销售公司和服务公司作为共同被告诉至法院是否合适?
      - 不合适。首先，两者属于法定法人、具备当事人能力，是适格当事人。其次，原告依据销售合同起诉违约，根据合同的相对性，销售公司并未直接对原告进行销售和服务，因此原告不是本诉的适格当事人
    - 2、当事人自述买车用途，未提出证据，对方未反驳，能否认可该事实?
      - 构成默示自认，法院应当将此事实作为裁判依据
    - 3、二审认为一审裁判错误，能否发回重审?
      - 认定事实错误，依法改判。要发回重审得认定事实不清或严重违反法定程序
    - 4、本案能否适用消法?
      - 适用。车非运营，用于商务接待。将车用于与工作有关的用途是个人消费者日常用车的常见情形
  - 案例二：不正当侵权纠纷
    - 1、法院是否具有法定管辖权？管辖权裁定不服如何救济?
      - 根据处分原则，原告可以选择恰当的请求权基础起诉，法院根据原告请求权确定管辖权。本案为侵权纠纷，应由被告住所地、侵权行为发生地、结果地管辖。原告住所地是侵权结果发生地，对本案具有管辖权。对管辖权异议裁定不服可向上级法院上诉
    - 2、法院是否应该依据管辖协议将案件移送?
      - 不应该。首先，协议管辖仅适用于合同或财产纠纷，本案侵权导致了原告财产利益受损，可适用管辖协议的约定。其次，本案中管辖协议的管辖条款属于格式条款，由被告提供。除非提供格式条款一方采取了合理方式提醒消费者注意，否则消费者可主张格式条款无效。格式条款提供方不合理免除或减轻其责任、加重对方责任，限制、排除对方主要权利的，该格式条款无效。本案原告非消费者，但

根据不当免除的规定格式条款依旧无效，双方间无管辖协议约定。因此，根据法定管辖，法院不应当将案件移送

- 3、原告提出的诉讼属于何种诉？若上诉后，原告申请撤诉，法院如何处理？
  - 不作为给付之诉，作为给付之诉，财物给付之诉，综上为给付之诉。原告对管辖权裁定提出上诉后，又申请撤诉的，法院应准予撤诉，对管辖权异议不再审查
- 4、用户在被告平台分享原告视频受阻，起诉被告的，诉讼程序如何进行？
  - 多人起诉可能构成普通共同诉讼，可以合并审理、可以独立进行，分别作出判决。若起诉原告达到10人以上，可以合并审理后由原告推选2-5名代表人进行代表诉讼

- 案例三：法人否认纠纷
  - 1、原告只诉一人公司股东，法院如何处理？
    - 法院应先向原告释明，告知应追加公司为共同被告。如不追加，由于原告与股东没有直接诉的利益，且原告与公司间的债权尚未经生效判决确认，不追加法院将驳回起诉
  - 2、股东与公司发生混同真伪不明，法院如何裁判？
    - 根据公司法规定，一人公司股东不能证明独立性的，应当对公司债务承担连带责任。在真伪不明时，法院应判负客观证明责任的股东败诉
  - 3、公司被纳入失信被执行人名单后，执行程序如何进行？
    - 公司没有可执行财产、纳入失信名单后，法院应裁定终本执行。后若发现有新财产线索，原告可向法院申请执行，恢复执行不受2年时效限制
  - 4、原告二次诉股东要求其承担公司连带债务的，当事人如何列明？原告对公司享有债权是否还需要举证？
    - 原告是原告，被告是被告，公司是第三人。题中原告对公司的债权已经法院生效裁判认定，属于免证事实，无需提供额外证据证明
- 案例四：网络侵权纠纷
  - 1、原告提的什么诉？
    - 行为与财物的给付之诉
  - 2、被告提出的管辖权异议，法院如何处理？
    - 作出驳回管辖权异议裁定，协议管辖约定的是合同纠纷，本案诉请的是侵权
  - 3、如答辩期内，被告没有提出管辖权异议且应诉答辩，则产生何种法律后果？
    - 视为被告对管辖权无异议，该法院有管辖权，但违反专属管辖和级别管辖的除外，法院不得移送管辖
  - 4、二审发现一审漏人漏判怎么办？
    - 漏人应有错必纠，漏判若当事人未上诉不告不理，上诉了先调解、调不成发回重审
- 案例五：著作权侵权纠纷
  - 1、多个起诉原告之一未参加诉讼，法院是否能依职权追加？

        - 彼此独立而同一种类法律关系为普通共同诉讼，原告不参加可以另诉，不允许追加
    - 2、本案诉讼在程序上如何进行?
        - 本案人数众多但总人数可确定，推选2-5名代表人普通共同诉讼，推选不出来当事人分别另诉
    - 3、案外著名编剧出庭属于什么诉讼地位？权利和义务如何?
        - 当事人聘请的专家辅助人，出庭发表的专业意见相当于当事人陈述。权利是要求聘任人支付必要费用，义务是出庭、接受对方和法庭的询问
    - 4、一审终审后，原告发现判错如何救济?
        - 一审判决已生效，可以向法院申请再审。由于原告均为公民、人数众多，可以向原审法院或上级法院申请再审
- 案例六：返还垫支款纠纷
    - 1、本案原告是否合法?
        - 可以，原告是破产清算期间法定民诉主体、具有当事人能力、直接利害关系，与本案有直接利害关系
    - 2、本案被告是否合法?
        - 合法，总公司和分公司是法定民诉主体、具有当事人能力、直接利害关系，可以一同当被告
    - 3、是否有管辖权?
        - 有管辖权，原告已进入破产清算阶段，有关其债权债务纠纷指向破产受理的法院集中管辖。合同约定的履行地与实际履行地不一致的，以约定履行地为准
    - 4、高院如何处理?
        - 破产法院将案件移送高院，高院若认为自己没有管辖权不能再次移送，应报请上级法院指定管辖
- 案例七：借贷合同纠纷
    - 1、原告是否需要举证证明借贷关系成立?
        - 是，一般证明责任法则是谁主张谁举证，原告有举证责任。案中被告自认理论上免除了原告举证责任。但本案可能涉及虚假诉讼，法院有义务查明，与法院查明情况不符的不得自认，原告依旧要举证
    - 2、被告妻子是否应以第三人身份参加诉讼？如果应以第三人身份参加，是哪种第三人?
        - 应当，本案处理结果可能有法律上的利害关系，无独三
    - 3、催款通知复印件的证据分类?
        - 间接证据，传来证据，本证
    - 4、催款通知是否可以采纳？证明力如何?
        - 可以。与基本事实相关，不属于应排除的证据类型，应当采纳。无法与原件比对证明力弱，不得单独作为定案依据

- 案例八：消费合同纠纷
  - 1、二审当事人地位如何确定?
    - 上诉人：销售公司，被上诉人：自然人，原告无独三：药厂。药厂一审没被判承担责任，因此无权上诉
  - 2、再审和发回重审适用何种程序?
    - 再审适用二审程序，发回重审适用一审普通程序，另行组成合议庭
  - 3、当事人管辖权异议是否符合法律规定?
    - 无独三不能提管辖权异议，一审应在答辩期内提，重审不能提管辖权异议
  - 4、被告反诉是否符合法定要件?
    - 反诉主体、管辖、牵连关系都符合法定要求，但再审原则上不能提反诉，告知另诉
- 案例九：货款纠纷
  - 1、证人出庭程序和其证言的效力?
    - 证人原则上要出庭，申请人在举证期间届满前提出申请，证人签保证书。证人与一方当事人有利害关系，证明力较低、不得单独作为定案依据。
  - 2、协议管辖是否有效?
    - 无效，仲裁、管辖协议必须书面
  - 3、被告撤回上诉后有什么效力?
    - 一审判决生效，和解协议没有强制执行力，可申请执行一审判决
  - 4、被告撤回上诉后，若认为一审判决存在错误，如何救济?
    - 知或应知的6个月内申请再审
- 案例十：确认人民调解协议案
  - 1、李如何实现调解协议中享有的权利?
    - 人民调解协议具有合同效力、无强制执行力，不执行的可依据协议向法院起诉，或双方共同向法院申请确认协议效力
  - 2、当事人如何向法院申请确认调解协议?
    - 本案并非法院邀请的先行调解，当事人申请确认调解协议的，双方共同在调解协议生效后30日内，向当事人住所地、标的物所在地、调解组织所在地的基院、中院提出申请
  - 3、若法院确认调解协议无效，当事人如何解决纠纷?
    - 可再申请调解，或就原纠纷起诉
  - 4、法院审理确认调解协议案，程序如何操作?
    - 简单案，组成独任庭，原则上不开庭，调解协议有效的确认有效，无效的驳回申请
- 案例十一：执行异议之诉
  - 1、原告如何实现生效判决权利?

        - 驳回案外人执行异议裁定后，原告应持生效判决，在判决生效2年内向原审法院或同级的被执行财产所在地法院申请执行
    - 2、案外人异议被驳回后，如何救济?
        - 原判决没有错误、判决债务不是执行标的，因此无需三撤和再审。案外人执行异议被驳回的，可提出执行异议之诉，原告是案外人，被告是执行申请人/债权人，要求中止执行、确认房产归自己、要求法院解封、返还房产
    - 3、案外人起诉后，程序如何进行?
        - 案外人异议之诉提起后，由执行法院管辖。执行法院受理案件后，原则上执行不停止。若案外人提供担保，可裁定停止执行；若申请执行人提供担保，可不停止执行。执行法院适用一审普通程序审理，案外人应对停止执行的权利举证
    - 4、为实现债权人款项和利息债权，法院可以采取哪些执行措施
        - 对债务人冻结、划拨、查封、扣押、拍卖、变卖等执行措施，也可使用搜查财产、对迟延履行处以利息等执行措施，还可以将其纳入失信被执行人名单、限制消费、报告财产、信用惩戒等
- 案例十二：存量房居间合同纠纷
    - 1、仲裁被申请人认为裁决错误，如何救济?
        - 收到裁决3个月内向仲裁委所在地中院申请撤销，或在债权人申请执行后向负责执行的法院申请不予执行
    - 2、被申请人向法院申请后，法院是否应撤销裁决?
        - 不应当，当事人的仲裁协议约定不明确、无效。但双方当事人未在庭前提主张仲裁协议无效，裁决作出后以此为由申请法院撤销的，法院不予支持。如果主张仲裁协议无效被驳回了，可在裁决后以此申请撤销裁决
    - 3、本案当事人对仲裁协议的效力存在争议，什么主体来确认?
        - 请求双方当事人所在地、仲裁委所在地、仲裁协议签订地中院确认，或仲裁协议约定的仲裁委，选了仲裁委不能选法院了
    - 4、若裁决被撤销，当事人可如何解决纠纷?
        - 原仲裁协议用过、失效，当事人可以达成新的仲裁协议去仲裁，或就原纠纷向法院起诉
- **三、官方用书民法案例**
    - （一）离婚案
        - 1、给女儿起名非主流是否符合姓名法的规定
            - 不符合，应随父姓或母姓，也可随祖父母、外祖父母姓，或其他抚养人姓氏
        - 2、男找派出所申办户口所形成的法律关系是否属于民事法律关系
            - 不属于，民事法律关系双方应为平等的民事主体，为行政行为
        - 3、男若认为派出所拒绝户口登记决定不合法，如何救济
            - 提行政复议或提行政诉讼，行政复议为最终裁决的除外
        - 4、空床费约定是否形成民事法律关系

- 不属于民事法律所调整的关系，约定也不产生民事法律关系效果
- 5、男经常夜不归宿违反了配偶关系的何种义务
  - 忠实、同居义务
- 6、男打女，医生存在过失致使手术损害，男与医生是否构成共同侵权
  - 不构成，医生不存在故意且无共同侵权合意
- 7、女提出医院赔偿祛疤费用、精神损害及违约金的诉请，是否支持
  - 不支持，医疗侵权仅能就违约或赔偿二选一
- 8、女提出医疗损害鉴定申请，是否支持
  - 支持，患者无法直接证明过错或因果关系时，可申请医疗损害鉴定
- 9、女提出离婚诉讼由什么法院管辖
  - 被告所在地，适用地域管辖一般规定
- 10、男提离婚诉讼，女在一审为主张离婚损害赔偿而在二审提，法院如何处理
  - 先调解，调解不成告知另诉，如双方都同意可二审一并审理
- 11、离婚诉中，男或女申请将医院列为第三人，法院是否准许
  - 不
- 12、男股票帐户的钱是否夫妻共同财产
  - 是，婚前投资婚后通过交易获取的收益，且并非孳息和自然增值
- 13、男、男弟和女签订担保书是否成立保证合同
  - 主合同不是债权债务合同

- （二）诉父母继承案
  - 1、列举本案涉及的民事法律关系，至少5个
    - 略
  - 2、诉讼1和诉讼2分别由哪个法院管辖
    - 诉讼1被继承人住所地、主要遗产所在地，诉讼2侵权行为地、被告住所地
  - 3、306房是否为夫妻共有财产
    - 是，物权登记与实际情况不一致的可申请确认其享有物权
  - 4、郭某阳是否为婚生子女
    - 订立人工协议时具有同意人工方式获得子女的意思表示，虽立遗嘱时反悔，不影响婚生性质
  - 5、男所立遗嘱未给郭阳留份额，是否有效
    - 该部分遗嘱内容因与胎儿强制预留份额的法律规定冲突而无效，没有保留的从遗产中扣回
  - 6、刘某对男是否构成一般侵权行为
    - 争议，略
  - 7、刘某对男侵权责任是否适用安全保障义务

        - 不适用，安全保障义务仅适用于公共场所的所有者、经营者，及群众活动的组织者
    - 8、如果夫妇拒绝签订个人信息处理协议，甲医院是否以此为由拒绝提供医疗服务
        - 不能，个人信息受到法律保护，不得以不同意信息处理而拒绝提供产品或服务
    - 9、男向刘某借款5万元，是否为夫妻共同债务
        - 没有用于共同生活的表示或经女追人，债权人若无其他证据证明则不构成共同债务
    - 10、诉讼2中，如果刘某以5万元债权主张抵销，是否形成反诉、是否获得支持
        - 不能，本诉为侵权关系、反诉为借款合同关系，不具有牵连关系，另外因故意、重大过失侵权赔偿不得主张抵销
    - 11、诉讼2中，刘某以郭某已确诊癌症晚期来否认原告的精神损害请求，是否成立
        - 不成立，假设的原因不产生事实上的原因力，侵权损害与疾病产生的精神损害不具有同一性
    - 12、郭某阳10岁时在学校导致同学重伤住院，同学将女诉至法院请求赔偿治疗费用，女抗辩称郭某阳有继承财产可赔偿，女应承担补充责任，法院如何处理
        - 责任分配上，监护人对娃侵权承担的是侵权责任、替代责任。执行上，可先执行娃财产，不足部分由监护人补充
- （三）移动通信合同案
    - 1、在业务窗口办理是什么意思表示，什么时候生效
        - 业务员对办理申请受领属于口头方式受领意思表示，以对话时知道内容时生效
    - 2、a分公司不具备法人资格，能否作为民事行为主体和被告
        - 非法人组织不能独立承担则然但仍能以自己名义从事各种民事活动和当被告
    - 3、与a分订立的电信服务合同何时成立
        - 签字盖章时生效
    - 4、与a分公司实施的抽奖行为是什么类型民事法律行为
        - 财产行为、双方行为、从行为、不要式行为、诺成行为、射幸行为
    - 5、服务协议规定停机约定是否意味着合同是附条件民事法律行为
        - 属于免责条款而不是附条件条款
    - 6、服务协议规定话费超过有效期1年是否有效
        - 无效
    - 7、服务协议规定管辖是否有效
        - 无效
    - 8、a分公司主张当事人并未要求提示所以应有约束力
        - 错误，格式合同的提示义务是法定义务
    - 9、电饭锅设计瑕疵造成火灾是否能请求a分公司予以赔偿

        - 有争议，如果认为是销售者则修、退、换、赔，如果认为不是持续销售行为则不承担
    - 10、能否提产品责任诉讼，请求厂家赔偿电饭锅
        - 能，电饭锅属于产品自损，可要求厂家或销售者赔偿
    - 11、能否向b保险公司请求支付保险金，没开保单、未交保费对保险请求有无影响
        - 能，保险销售与当事人达成一致后保险合同生效并对保险公司产生效力
    - 12、b保险公司支付了保险金能否向a分公司追偿
        - 看情况，视为销售则可追偿，不是销售不能追偿
    - 13、起诉a分公司要求取消话费有效期限制、恢复服务，是否可独任审理
        - 基层院的简单案可适用独任审理，且不属于国社他、群体性纠纷、新情况等不适用情形
- （四）张三担保案
    - 1、继承旺铺后转让过户，两人能否请求基于转让协议办理转移
        - 不能，先继承登记，后转让过户登记
    - 2、借款诉讼时效届满后主张债权，丙的抵押权效力如何
        - 抵押权有效，但抵押人享有时效抗辩权
    - 3、张三能否取得轿车所有权
        - 不能，出让后继续占有动产，自占有改定交付时所有权转移，机动车未经登记不得对抗善意第三人。后无偿赠予善意第三人张三后，虽为张三办理了登记但未交付、未支付合理对价，不满足善意取得所有权的要件
        - 不能，动产交付后所有权转移
    - 4、丁的质权是否设立
        - 设立，质押合同属于单务、无偿合同，交付车给善意的丁设立
    - 5、如丁的质权未有效设立，保证人将借款本息向丁进行了全额清偿，戊能否向戍进行追偿
        - 不能，混合担保的担保人间追偿，应以有明确约定或共同担保的意思联络才认可追偿权的存在
    - 6、如冯明知金表上设有质权仍留置，其是否享有优先受偿权
        - 有，对质权物留置仍然具有优先权，不受善意恶意影响
    - 7、冯能否拒绝王某以品牌包换回金表的诉求
        - 不能，债务人另行提供担保的留置权消灭，一般而言留置权人不能拒绝另行提供的足额担保
- （五）江汉农商银行动产担保案
    - 1、钻石项链制作完成后拒不支付材料和加工款8000，如何救济
        - 钻石由定作人提供，添附后属于定作人，承揽人可向法院主张支付报酬，或主张留置并就拍卖变卖价款优先受偿

- 2、将现有设备和动产为江汉农商行设立的抵押权是否成立
  - 成立，动产浮动抵押，登记不是成立要件、是对抗要件
- 3、乙公司的动产抵押权与农商银行的抵押权何者优先
  - 价款担保权优于先登记的动产浮动抵押权
- 4、丙公司的留置权、丁公司的抵押权是否设立，谁优先
  - 设立，留置权人将留置物无权处分并设定抵押权，满足善意取得的条件、丁的抵押权设立，物上抵押权效力优先于留置权
- 5、丙公司的法人将a设备擅自质押给刘某，刘某质权是否优先
  - 刘某善意取得a设备质权，丙公司失去占有、失去质权，丁公司抵押权未登记，无法对抗刘某质权

- （六）旅行社案
  - 1、可否请求驾驶员、巴士公司承担损害赔偿责任
    - 巴士公司作为用人单位应承担侵权责任
  - 2、乙旅行社辩称应由巴士公司赔偿，是否成立
    - 不成立，对巴士公司选择未尽审查义务，乙应承担侵权赔偿
  - 3、能否请求乙旅行社承担违约责任
    - 不能直接请求承担违约责任，与甲签的合同
  - 4、甲旅行社辩称第三人行为导致应根据合同免责，是否成立
    - 不成立，格式合同
  - 5、能否请求甲旅行社承担侵权责任
    - 不能，甲对损害后果没有主观过错、无法律因果关系
  - 6、若以甲乙旅行社为被告，放弃对甲的追偿，乙能如何主张
    - 最高法关于旅游纠纷的规定，甲乙旅行社承担连带责任，难以认定为同等责任，放弃对甲追偿，乙可主张在同样免责
  - 7、可否请求丁承担损害赔偿责任
    - 无偿帮工遭受损害的，可以要求补偿
  - 8、亲属能否以无法预见殴打致死而主张免责
    - 不能
- （七）银河财政局股权转让合同案
  - 1、财政局与星河公司的转让合同效力如何
    - 合同成立，审批机关批复后生效
  - 2、财政局主张审批机关作出的终止函时合同已解除，是否成立
    - 不成立，终止报批不影响合同继续成立，双方未解除合同或约定单方解除权
  - 3、银河财政局与星河公司转让合同是否已经解除
    - 未解除

- 4、星河公司起诉是否过时效
  - 未过时效，以最后一次函件主张继续履行起算诉讼时效
- 5、银河财政局应赔星河公司交易费用吗
  - 应，报批义务人迟延报批
- 6、星河公司主张财政局与山河公司的转让合同无效，是否支持
  - 不支持，不存在法定无效事由
- 7、山河公司如何救济
  - 要求履行报批义务，或主张解除合同、赔偿责任

- （八）东方公司合同纠纷
  - 1、张某是否有权解除合同
    - 不能，张某未经催告即提出解除，且对方第二天已付款
  - 2、李某主张合同未解除是否成立
    - 成立，无解除权李某无需异议
  - 3、安达公司是否有权解除合同
    - 有权依据情势变更行使法定解除权
  - 4、安达公司是否有权要求违约赔偿
    - 政府政策调整属于不可抗力，免除违约责任
  - 5、东方公司是否能扣违约金
    - 双方达成补充协议，构成对原合同的变更，未延期交付未违约
  - 6、东方公司是否可以要求嘉美赔偿
    - 嘉美在前期施工中存在过错，
  - 7、东方公司增资决议和方案3条是否有效
    - 决议有效但方案3条无效，优先认购权不得以多数决方式剥夺
  - 8、董事会做法是否合法
    - 有权提任意公积金由股东会决定，不合法
  - 9、钟某如何维权
    - 钟某可以提决议效力确认之诉
  - 10、东方公司如何救济
    - 要求退换修，及承担其他赔偿责任
- （九）通讯公司卖房案
  - 1、售楼部展示的车位宣传资料可否构成合同内容
    - 赠送车位宣传资料具有相当的经济价值且信息明确，作为影响购买意思的判断因素，宣传资料属于要约，构成合同内容
  - 2、购房协议是预约还是本约

- 预约，约定将来要订立一个新的协议且订立后购房协议失效，购房协议没有约定所有内容
- 3、甲方与乙方房屋买卖合同是否成立
  - 预约后，一方履行另一方接受的视为本约成立
- 4、购房协议签字但无乙方章，对乙方是否发生效力
  - 以法人名义订立且法定代表人签字，未越权且未约定必须为盖章要式合同则合同成立
- 5、甲将a房屋卖给第三人，对乙是否违约
  - 预约违约
- 6、乙请求甲履行b房产过户手续，是否支持
  - 支持，本约成立
- 7、乙请求甲双倍返还定金2000万，是否支持
  - 部分履行合同且对方接受，主张定金罚则的应按比例，除非部分违约导致全部无效
- 8、乙诉请3和4是否能同时主张
  - 定金罚则不足以弥补损失的，可请求差额赔偿损失
- 9、乙依据购买同地段类似户型的差价计算赔偿数额，是否支持
  - 不能完全支持，有架空预约合同制度嫌疑
- 10、甲方请求乙方支付b房屋占有使用费，是否支持
  - 不
- 11、对于丙就b房屋申请实现抵押权，乙提异议的，是否支持
  - 不能支持，非居住目的、未支付价款超50%

- （十）村委会与旅游公司经营协议案
  - 1、未起诉镇政府，可否追加其为第三人
    - 镇政府不属于必要共同诉讼人，追加无独三
  - 2、水务局将开发区域划定为城市蓝线是否构成情势变更
    - 不构成，不属于完全无法预见的非商业风险，且可通过报批等方式寻求继续履行合同
  - 3、旅游公司构成什么违约，是否能要求继续履行
    - 拒绝履行非金钱债务，政策阻碍、不能要求继续履行
  - 4、镇政府未回复旅游公司提出的解除是否导致合同已解除
    - 不享有解除权的不发生解除效力
  - 5、乙方有权请求法院终止合同
    - 合同陷入僵局，可请求法院终止协议
  - 6、甲方请求是否支持
    - 预期开发可的利益不支持

- 7、甲方赔偿损失请求，乙方可否主张损益相抵
  - 买卖合同可主张相抵，开发合同可参照买卖合同相抵
- 8、返还合作费用是否支持
  - 合同终止后，已经履行的可请求恢复或返还
- 9、100万违约金可否主张
  - 惩罚性约定与填补损害请求可以并举
- 10、镇政府要求赔礼道歉是否成立
  - 仅适用于人格侵权，不支持
- 11、建设工程案可否合并审理
  - 不
- 12、分期执行的，申请执行时效如何起算
  - 最后一期起算

- （十一）郑某汽车买卖案
  - 分析全部关系，略
- （十二）买卖手机、宠物合同案
  - 1、是否有权要求免费修手机
    - 隐蔽瑕疵，无约定、根据性质和习惯，在合理期限内通知瑕疵，应免费修手机
  - 2、买卖合同是否成立
    - 迟到的承诺视为新要约，回复时合同成立
  - 3、小狗属于谁
    - 所有权转移后天然孳息，属于买家
  - 4、丢失的狗粮谁承担
    - 未约定交货地，货交承运人转移灭失风险
  - 5、找哪个法院起诉
    - 略
  - 6、能否要求返还3只狗和价款
    - 无权处分不影响合同效力，欺诈狗品种构成可撤销合同，1年除斥期间内主张
  - 7、钱某是什么诉讼身份
    - 无独三
  - 8、王某能否要求取回手机
    - 保留所有权买卖合同，已支付超总价款的75%，不能取回
  - 9、保险公司是否能以违反如实告知义务解除合同
    - 保险公司明知而据此主张解除的，不支持
  - 10、宠物狗买卖合同撤销后，受让人能否取得狗所有权
    - 欺诈撤销合同后，受让人不能取得所有权

- 11、宠物狗买卖合同撤销后，返还前狗丢了怎么办
  - 无权占有人不返还构成恶意占有，狗丢了要赔
- 12、若张某将狗赠予他人，是否能请求他人返还
  - 未支付合理对价，不善意取得

- （十三）生物科技公司网购合同案
  - 1、网购合同是否属于书面形式
    - 随时查用的数据电文，属于书面形式
  - 2、缔约过程中如何认定要约和承诺
    - 网店发布信息属于要约，提交订单属于承诺
  - 3、合同什么时候成立
    - 提交订单成功，合同成立
  - 4、交付标的物时间如何认定
    - 交付标的物时间是收货时间
  - 5、旺旺对话是否是民事证据
    - 是
  - 6、能否请求法院调取订单信息
    - 可
  - 7、网店是否属于欺诈
    - 是，虚构原价属于价格欺诈，约定标准高于法定标准，可按约定标准索赔
  - 8、能否要求精神损害赔偿
    - 不能，用于侵权案件
  - 9、能否要求直播间承担连带责任
    - 能，直播间明知价格欺诈损害消费者利益
  - 10、是否有权请求电商平台承担责任
    - 无权，没有证据表明平台应担责
  - 11、法院是否应追加物流公司为共同被告
    - 不应，快递公司不属于同一诉讼标的、不属于必要共同诉讼
  - 12、开庭审理可否通过网络平台在线进行
    - 经同意，可以
- （十四）租赁合同案
  - 1、租期25年是否有效
    - 超过20年的部分无效
  - 2、租赁登记备案没办是否影响合同效力
    - 合同约定备案起生效，但双方依据合同履行了各自的权利义务，以默示合意改变了合同约定的生效条件

- 3、要求支付租金能否得到支持
  - 承租人向原房东提交支付了转让后的租金，转让合同无约定的新房东可向原房东主张不当得利返还
- 4、承租人要求确认房屋买卖合同无效，能否得到支持
  - 不能，未通知侵害优先购买权，不能主张合同无效可要求赔偿
- 5、诉请解除行为无效，能否得到支持
  - 略
- 6、解除合同可否直接起诉解除而不通知
  - 可，起诉解除胜诉的，溯及至收到起诉状副本时合同解除
- 7、乙要求甲继续履行租赁合同，能否得到支持
  - 一般应继续履行，除非超过请求时效、不适合强制履行、不能履行的
- 8、转让房屋后转租，丁要求甲赔偿，是否成立
  - 转租合同有效，转租行为造成出租人损害可索赔

- （十五）苏芳、颜香侵权责任案
  - 1、主张产品责任侵权，是否支持
    - 原告无法举证死亡结果是产品缺陷导致
  - 2、公司辩称促销宣传与其无关，是否支持
    - 不，法定代表人或职员在职权范围内以公司名义实施的宣传行为，对公司发生效力，虚假宣传或欺诈行为后果归属于公司
  - 3、主张按照公平原则减轻赔偿责任，是否支持
    - 过错相抵原则，主张苏芳明知诊断问题未作进一步治疗，支持
  - 4、原告诉请要求双倍货款返还，是否支持
    - 支持，消保法规定了欺诈时3倍赔偿损失权利
  - 5、主张误工、护理、医药、丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、精神抚慰金，是否支持
    - 不，无证据证明公司违规宣传与死亡结果之间存在因果关系
  - 6、吃饭未结账被追摔倒要求赔偿，是否支持
    - 追赶属于自助行为，过程没有存在不当之处，不支持
  - 7、路人被追赶车撞伤要求赔偿，是否支持
    - 本案不属于共同侵权，共同危险，各自过错导致承担按份责任
  - 8-9、略
- （十六）蜜蜂蛰人案
  - 1、卖蜂人是否要承担侵权责任
    - 动产未交付蜜蜂仍属于卖蜂人，动物饲养人或管理人要担责
  - 2、如只起诉其中一名卖蜂人，法院直接驳回起诉是否正确

- 不正确，应追加
- 3、代书遗嘱律所过失是否应承担赔偿责任
  - 应，代书应安排2名却只安排1名律师，过失导致遗书无效并造成继承人损失
- 4、律所投了职业责任险，律所与原告私自达成赔偿协议，后原告诉保险公司要求支付保险金，保险公司主张原告不是保险当事人
  - 保险法规定，被保险人怠于请求保险公司承担赔付责任的，第三人可以直接请求保险公司赔付。被保险人与第三人达成和解协议、未经保险公司认可的，保险公司可以主张重新核定。
- 5、司机雇主是否承担补偿责任
  - 司机在驾驶期间遭遇到第三人共同危险损害，司机有权请求第三人赔偿，也可请求雇主补偿
- 6、司机为避免迎面而来的汽车猛打方向盘而撞伤路人，谁担责
  - 迎面汽车，若司机紧急避险过当则司机雇主也要担责
- 7、股东会未开会伪造了会议决议
  - 会议决议不成立，股东会撤销之诉以作出决议为前提
- 8-11、略

- **四、官方用书民诉案例**
  - （一）校内儿童伤害案
    - 1、法院是否可追加小学为当事人，为什么?
      - 可以。根据民法典和民诉解释的规定，无、限制民事行为能力人在教育机构遭受第三人侵权伤害，未尽管理职责的教育机构对侵权责任人赔偿不足范围能承担补充责任。本案中教育机构不是适格的共同诉讼被告，与案件处理结果可能有利害关系，法院可追加其为无独三
    - 2、本案适格被告是否包括打人小孩?
      - 包括。根据民法典和民诉解释的规定，小孩及其监护人为侵权责任的共同被告。且小孩以被告身份参与诉讼有利于查明案件事实，执行时也应优先执行小孩财产、不足部分由监护人承担
    - 3、针对远方亲戚中止诉讼、重新指定小孩遗产管理人的申请，法院如何处理?
      - 驳回申请。首先，指定遗产管理人案由被继承人所在地和主要遗产所在地管辖，远房亲戚申请的法院无管辖权应驳回。其次，远方亲戚并非侵权案当事人、不具备代理人身份，无权向法院提出中止
    - 4、法院是否能将小孩和取得监护权的邻居纳入失信人名单?
      - 不应当。无、限民事行为能力人没有处分财产的行为能力，不存在恶意逃避债务的情形，且邻居在案发后才取得监护权、不能成为本案的被执行人，因此均不能纳入失信人名单
    - 5、邻居申请法律监督，检察机关如何处理?

        - 驳回申请。当事人申请检察监督的前提是已经穷尽其他手段，本案当事人未上诉、未申请再审，不能直接申请启动法律监督
- （二）画廊古画案
    - 1、画廊向c法院起诉返还古画，甲公司以画廊转让协议约定的b法院管辖为由提异议，c法院如何处理?
        - 驳回异议，将案件移送有管辖权的b法院。协议约定画廊转让交易涉及的纠纷由b法院管辖，古画与转让交易有事实上的关联但无法律上的关联，且画廊明确答复甲公司古画不属于转让协议涉及的可自由处置的范畴，转让交易与画廊委托甲公司保管古画的约定无关。保管纠纷依据一般地域管辖原则由被告住所地管辖，即b法院具有管辖
    - 2、画廊希望避免古画因甲公司欠修复费用而被法院拍卖执行，作为律师提供建议
        - 画廊是古画的所有权人，修复师傅王某诉甲公司、留置古画并申请拍卖受偿一案中，画廊的身份是有独立请求权的第三人。画廊应先向执行法院提执行异议，由于王某案中法院判决没有错误，画廊在执行异议被驳回后无法提执行异议之诉，可在知或应知6个月内向原审法院提第三人撤销之诉，或申请再审。同时，由于画廊也可代甲公司支付修复费用，解除留置后向甲公司追偿
    - 3、如画廊诉甲公司未付转让尾款，甲公司主张已以现金支付，谁承担证明责任
        - 甲公司。画廊诉甲公司实质是基于未付尾款而进行的拒绝履行过户的同时履行抗辩，甲公司的主张目的是消除此抗辩权，根据证明责任的分配原理，应由主张权利消灭的甲公司承担证明责任
    - 4、甲公司诉画廊拒绝过户，画廊在一审中因当地房价涨价不愿意卖了、提情势变更解除合同，此为反诉还是抗辩
        - 反诉。原审原告为甲公司、被告为画廊，甲公司诉请画廊向自己履行过户的合同债务，画廊作为违约方没有对甲公司的抗辩权。由于当地地价发生较大变化，为订立转让协议时无法预知的情形，画廊以原审原告为被告起诉要求以情势变更解除合同，与原审具有牵连关系因此为反诉
    - 5、画廊要求解除查封并愿意提供价金担保，甲公司坚决反对担心画廊被高价卖出，法院如何处理?
        - 驳回解除查封申请。申请解除保全需提供有效的等值担保财产且有利于执行，画廊作为本案争议标的，仅提供价金担保并不能保证将来的执行，且未获得保全人同意
- （三）a委托b银行给c房地产公司提供贷款案
    - 1、a公司是否可基于民法典925条行使介入权，向c公司主张权利
        - 不可以。基于民法典925条，第三人知道受托人系根据委托人授权订立合同的，该合同直接约束委托人和第三人。除非有证据证明合同只约束受托人和第三人。委托借款协议是涉他合同而非隐名合同，且明确约定放款与收回的主要权利义务限于bc之间，不能依据民法典925条介入。
    - 2、a公司所在的法院是否有管辖权

        - 没有。首先，a公司不是本案的适格原告。a公司不能行使介入权，并非借款协议的约束主体，与本案没有直接的利害关系，不是本案的适格当事人。其次，委托贷款协议约定借款纠纷a公司委托b银行提起，诉讼实施权已委托b银行，有管辖权的法院为b银行所在地法院
    - 3、法院依据驳回的管辖权异议，在一审判决中直接支持了a公司的诉讼请求，根据民诉法原理和相关法规评价
        - 做法错误。管辖权争议判定的是受诉法院是否有管辖权，属于程序问题，诉讼争议的焦点是适格当事人的认定，属于实体问题，需要法院依据证据和事实进行判定，管辖权异议驳回不属于实体审理中的免证事实，程序判断也不能代替实体判断。
    - 4、a公司对购房人金某提执行异议之诉，法院如何处理?
        - 驳回a公司的执行异议之诉。买受人签订合法有效的购房合同、已支付全部价款、已实际占有房产，能够排除一般的金钱债权强制执行。买受人签订合法有效购房合同、已支付全部价款、首套刚需房，能够排除建设工程价款优先权、抵押权及一般金钱债权的强制执行。
- （四）网购买鞋
    - 1、哪些法院有管辖权
        - 被告住所地、网购收货地、杭州互联网法院
    - 2、受诉法院如无管辖权如何处理
        - 法院审查后可依职权移送至有管辖权的法院，被告在答辩期内可提管辖权异议
    - 3、旺旺截图属于什么证据
        - 电子数据
    - 4、卖家主张删帖、声誉赔偿等是否构成反诉，能否合并审理
        - 本诉标的是网购买家、卖家间的网购合同纠纷，及买家与网购平台服务合同纠纷，卖家诉请与本案具有事实和法律上的牵连关系，构成反诉。合并审理有利于提高效率、查明事实、避免分别审理导致的相悖裁判，可合并审理。
- （五）见义勇为救小孩被撞案
    - 1、被撞死者亲属是否能将肇事司机作为被告诉至法院
        - 可以。案发后肇事司机作为明确主体、符合起诉条件，可作为被诉主体诉至法院。法院在审理中依据查明的事实对适格被告及其责任进行认定，本案承担侵权责任的应是车辆所有人，仅起诉被雇肇事司机的法院应向原告释明，不更换被告的则驳回原告诉请。
    - 2、法院能否依据司机申请将车主和登记公司最追加为共同被告
        - 不能。司机并非本案适格被告，三者无共同的诉讼标的
    - 3、法院能否依据保险公司申请追加小孩监护人为无独三
        - 能。本案区分为交通侵权与无因管理救助两组法律关系。就交通侵权而言，小孩擅闯道路造成了交通风险，监护人与司机、保险公司应为共同被告。原告仅起诉

司机，法院应向原告释明是否追加。就无因管理救助关系而言，监护人对见义勇为的侯某获赔不足部分承担补偿责任，监护人可作为辅助型第三人追加进来。

- 4、如何认定交通事故认定书的效力
  - 属于公文书证，一般具有较高证明力，有相反证据可推翻，关于最终证明力与是否采信根据法庭审理而定。
- 5、原告不愿意追加监护人，判决后是否能再起诉
  - 可以，普通共同诉可合可拆。

- （六）机场托运茅台遗失案
  - 1、谁有管辖权
    - 旅客可基于航运合同主张违约责任，也可基于侵权事实主张侵权责任，请求权竞合，主张不同管辖不同。若基于航运合同，航运始发、到达地和被告住所地管辖，此时被告仅为航空公司；若基于侵权，侵权行为地和被告住所地管辖，被告仅为机场。
  - 2、谁是适格被告
    - 基于合同违约是航司，基于侵权是机场。
  - 3、被告主张旅客迟到转盘取件，是否对此承担证明责任
    - 被告提出的是免责、减责主张，根据谁主张谁举证原则由被告负证明责任
  - 4、损害数额原被告主张不同，谁证明
    - 一方面，航司已对8千的保价自认，无需承担证明责任。另一方面，就8千至6万元的部分，无论是合同违约诉还是侵权诉，原告负担证明责任。
  - 5、结合生活常识原告如何证明自己拖运物是茅台
    - 托运视频、购买发票、行程信息
- （七）低价卖房规避债务
  - 1、甲公司向仲裁委申请仲裁乙丙的合同无效，仲裁委是否受理
    - 不受理，无仲裁协议仲裁委不予受理。
  - 2、海淀区法院是否有管辖权
    - 本案属于商品房买卖纠纷，不属于不动产专属管辖6
  - 3、甲公司请求将涉案房屋归复至乙公司名下，是否违反了处分原则
    - 不违反。乙丙公司具备关联性，以明显低于市场价格转让房产，具有恶意规避对甲公司到期债务的行为，推定丙公司恶意、转让行为无效。
  - 4、若甲乙丙三方达成和解协议申请法院制作调解书，法院如何处理
    - 即便是私下达成和解且和解内容超过诉讼请求范围，法院也应同意制作调解书
  - 5、如果法院驳回甲公司全部诉请，是否还能告乙公司请求撤销合同
    - 两者本质上是一个诉，不应受理
- （八）排污生态环境侵权

- 1、有排污行为、鱼塘鱼死、河鱼正常且经常有人钓鱼、污染后未及时隔断水源，以上事实谁承担证明责任
  - 有排污行为属于加害行为、鱼塘鱼死属于加害后果，由原告负证明责任，河鱼正常且经常有人钓鱼属于切断因果的主张由被告负证明责任，未及时切断水源属免责的主张由被告负证明责任
- 2、被告向法院申请再审同时是否能向检察院抗诉
  - 不能。三种情况可向检察院申请抗诉或提检查建议，法院驳回再审申请或逾期再审申请，再审判决、裁定有明显错误。
- 3、被告申请再审向哪一级法院提出？再审事由成立的由哪一级法院再审？
  - 本案一审为基院，二审为中院，被告对生效二审不服应向高院申请再审，再审原则上由高院审理，涉及基础性事实或证据问题没搞清的也可指令二审法院再审
- 4、被告申请再审的依据是什么
  - 主要证据未经质证，当事人申请再审的法院应当再审
- 5、一审遗漏处理诉请，再审法院如何处理
  - 原告未上诉也未就此申请再审，且未侵害国社他利益，不干预
- 6、案外人c建筑公司对被执行的楼如何救济其工程款
  - 先提执行异议，然后以债权人为被告提执行异议之诉

- （九）老王遗产案
  - 1、老王是否能申请宣告王大失踪
    - 王大下落不明满1年，老王作为近亲属有权提出宣告失踪申请
  - 2、法院是否应该批准王二变更财产代管人的申请
    - 应批准。财产代管人不仅包括近亲属，还可以是其他关系密切的亲朋好友，遵循有利于保护失踪人财产的原则可变更。
  - 3、如王三认为老王临终前订立遗嘱时不具备完全民事行为能力，不应按老王异性好友李某声称的遗嘱确定其为遗产管理人，应向哪个法院寻求救济
    - 公证遗嘱一般有较高证明力除非有相反证据能够证明，有遗嘱执行人时法院应指定其为遗产管理人，除非王三有明确证据否则可能承担败诉风险。遗产纠纷以被继承人生前居住地和主要财产所在地为地域管辖法院地，专属管辖。
  - 4、李某导致老王车辆损坏，法院能否根据利害关系人申请撤销其管理人资格
    - 不能。遗产管理人故意侵害其他继承人或管理财产利益的，法院能根据利害关系人申请撤销其管理资格。李某没有故意导致车辆及继承人损害的行为与严重后果。
  - 5、如果王三向法院起诉要求分割遗产，王二放弃、王四主张按遗嘱，大二三四处于什么诉讼地位?
    - 如果王大未被宣告死亡，不同意王三诉请又不放弃遗产继承权的，王大与王三一同作为共同原告，未追加法院要追加。王二如放弃所有继承权则不必列为当事人，如仅同意遗嘱继承则与王四一同列为被告。

- 6、王三配偶要求离婚分割王三可能获得的遗产，法院是否支持
  - 支持。一方继承财产原则上属于夫妻共同财产，未分割完毕的在离婚诉后另诉
- （十）诚信公司违约被黄某执行案
  - 1、诚信公司股东赵某认为自己已经付了400万，只需再付600万，如何表述?
    - 判决生效后，债务人向债权人的清偿行为构成债权消灭。债务人异议参照债权人异议处理。赵某清偿400万债务后，可对1000万执行提出异议。
  - 2、法院在发出执行通知前就将诚信公司纳入失信名单，是否符合规定?
    - 符合。执行员接到执行申请或移交执行书时可立即采取强制执行措施，并不以发出执行通知和同执行通知到达被执行人为前提
  - 3、法院将赵某追加为被执行人的做法，是否符合规定?
    - 赵某是诚信公司的唯一股东，诚信公司是赵某的一人公司。赵某若不能证明其财产独立于一人公司的，可在执行中直接追加赵某为被执行人，本案中执行申请人能够证明混同因此可以执行
  - 4、法院执行赵某名下房产的做法，是否符合规定?
    - 符合。金钱债权执行中，对执行人和抚养家属，应保留义务教育与日常生活的必要部分。本案赵某另购有两套住房登记在其子名下，可对上海住房执行
  - 5、法院执行赵某名下股权的做法，是否违反执行规定?
    - 不违反。金钱债权执行中，股权属于被执行合法对象
  - 6、法院是否会支持赵某执行异议申请?
    - 支持评估资质异议，不支持法官异议。承办人员不属于执行过程的具体执行行为，不在可异议范围之内
- （十一）大力公司仲裁案
  - 1、约定一方所在地仲裁委管辖是否有效
    - 所在地仅有一家仲裁委，有效
  - 2、申请撤销裁决时认为双方不存在仲裁协议，法院是否会支持
    - 当事人对仲裁协议效力有异议，应在首次开庭前提出，在作出生效裁决后提出不予支持
  - 3、大力公司申请撤销仲裁时认为仲裁庭违反了民诉法的程序规定，法院是否会支持程序违法
    - 仲裁庭未允许复制庭审笔录和调取录像，不违反仲裁法和仲裁规则的规定，且申请撤销不应依据民诉法
  - 4、大力公司认为仲裁庭有枉法裁判行为，法院如何认定枉法裁判
    - 枉法裁判应经生效刑事裁判确认，否则以此为主张撤销裁决不予支持
  - 5、在仲裁执行过程中，大力公司是否能申请不予执行仲裁裁决
    - 申请撤销裁决被驳回的，在执行中以同样理由申请不予执行的，不支持
- （十二）涉外管辖案

- 1、约定管辖是否有效？应适用哪国法律？
  - 协议管辖适用法院与适用法律是两类问题。本案建设工程位于缅甸、不适用不动产专属关系的规定，协议中国法院管辖有效。协议适用法律仅包括实体规范，不包括冲突规范和程序规范。
- 2、约定管辖是否有排他效力？
  - 约定管辖未明确是否有排他效力，全国法院涉外商海事审判工作座谈会会议纪要表明推定排他
- 3、本案能否以不方便法院审理为由驳回起诉
  - 不存在管辖权协议、不违反专属管辖规定、不涉及主权安全或社会公共利益、案件争议事实不发生在境内、外国审理更方便是不方便审理的前提，本案有管辖权协议，不适用、不能驳回